

1500859-14.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... que a favela é um local conhecido como tráfico de entorpecente. Localizaram o réu em atitude suspeita trazendo com ele entorpecente. Uma moto parou próximo a ele e deu a entender que ele seria o responsável pelo tráfico no local. Com ele estavam as drogas e dez reais em dinheiro. O réu alegou que estava ali para compra de entorpecente e que seria usuário. Não conhecia o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500859-14.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000673

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115795/2022 - 03º D.P. DIADEMA, 24618226 - 03º D.P.

DIADEMA, 2115795 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ SILVA DUARTE

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JORGE LUIZ SILVA DUARTE, qualificado a fls. 16, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta das 18h30, na Avenida Fundibem, n.º 128, bairro Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 09 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 4,22 gramas, 05 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 1,9 grama e 02 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 13,12 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação provisória de fls. 11/13.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.30/32), o réu foi notificado e citado (fls. 68 e 130), e apresentou defesa preliminar as fls.71/78, através do Advogado constituído. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 02/08/2022 (fl.96).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base no mínimo, com o aumento pela reincidência, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, além da perda do numerário apreendido.

Já o d. Advogado reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória e contradições nas falas dos policiais. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.09, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.11/13 e 124/126), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.06/07) compareceram ao local dos fatos, suspeito por seu comércio ilegal de entorpecentes, e ali avistaram um indivíduo, que então, sob fundada suspeita, decidiram por abordá-lo. Identificado como Jorge Luiz Silva Duarte, após revista pessoal, foram encontrados em seu bolso 5 invólucros de substância aparentando ser crack, bem como a quantia de R\$ 10,00 e em um maço de cigarro que estava ao lado do indiciado abaixo de um madeirite, com mais 9 papéletes de substância aparentando ser cocaína e 02 de substância aparentando ser maconha.

Sob o crivo do contraditório o policial José Antonio dos Santos respondeu que a favela é um local conhecido como tráfico de entorpecente. Localizaram o réu em atitude suspeita trazendo com ele entorpecente. Uma moto parou próximo a ele e deu a entender que ele seria o responsável pelo tráfico no local. Com ele estavam as drogas e dez reais em dinheiro. O réu alegou que estava ali para compra de entorpecente e que seria usuário. Não conhecia o réu e nunca o viu antes naquela biqueira. Reconhece o acusado. Às reperguntas do MP disse que um motoqueiro parou próximo ao réu, e estendeu a mão, e nesse momento abordaram eles, mas o motoqueiro fugiu. As drogas estavam no bolso do réu. Às reperguntas da Defesa, ratificou seu depoimento, justificando que tem feito muitas incursões ao combate ao tráfico e não se lembra de pormenores. De fato, no local há um mercado e cultivo de temperos naturais dentro de um cercadinho e de fato, tinham drogas embaixo de um madeirite e

com o réu também. O réu se dirigia até o local para pegar a droga e servir, o que foi visualizado numa campana por uns dez a quinze minutos, e já sabiam que o réu guardava as drogas ali.

Igualmente o policial Ricardo Gomes de Oliveira respondeu que o local é conhecido como ponto de venda de droga. Observaram a movimentação por uma breve campana e perceberam que o réu Jorge estava em atitude suspeita porque já havia passado algo a outrem, o que sugeriu ser droga. Abordado, com ele localizaram drogas e dinheiro, e perto dele havia um madeirite e ali estava o restante das drogas. Reconhece o réu, quem disse ser usuário e que estaria ali para comprar droga. Mas viu o réu praticando atos de mercancia. Não conhecia o acusado e não o tinha visto antes no local. Não se recorda se houve a presença de moto quando da prisão do réu, mas no mesmo local fizeram outras três prisões, e não tem lembrança dos detalhes. Às reperguntas das Partes, respondeu que notou que o réu já tinha uma quantidade pequena de droga no bolso, para descaracterizar o tráfico caso não fosse encontrado mais narcótico, mas no caso do réu, o viu, efetivamente, entregando algo a outrem, e pareceu ser droga, tanto que ao ser revistado, em poder dele estava parte das drogas e dinheiro. A droga mais vendida é o crack e custa cinco reais. Com o réu tinha cinco porções de crack e dinheiro, e perto dele estava o restante, num maço de cigarros.

O réu, em solo policial (fl.08) respondeu que estava no local comprando crack quando foi abordado pelos policiais.

Em juízo o acusado disse que no dia tinha chegado no local para comprar sua droga de preferência, pois é dependente químico e morava na rua. Comprou a droga e virou a esquina. Veio um carro preto e mandou ele deitar no chão. Ficou assustado e já falou que tinha só comprado a droga. Foi levado até a esquina onde tem um terreno, onde acharam outras drogas e o cara que lhe vendeu não estava mais lá. Ganhou sessenta reais por tirar entulho de uma mulher. Pagou as drogas, deixou dois reais de caixinha para o traficante, e ficou com oito reais de troco. Ficou internado em diversas clínicas no interior, pois fuma maconha desde os dez anos de idade, e depois conheceu o crack e desde então piorou. Já foi preso por roubo.

Logo, os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, dado que sua versão de que estaria no local apenas para comprar crack não restou por si, nem pela Defesa demonstrados, e em sentido contrário tem-se que o réu estava sozinho na biqueira, e foi visualizado pelos dois policiais, quando da campana que fizeram por uns dez minutos, efetivamente entregando algo a outrem, no ponto de venda de drogas, o que ensejou a abordagem, tanto que em poder do réu estavam cinco pedras de crack mais uma quantia em dinheiro, e próximo a si, embaixo de um madeirite, dentro de um maço de cigarros, localizaram o restante das drogas, pois já tinham visto o acusado ir até aquele local pegar droga.

Desde já afastou alegação da Defesa no sentido de contradições nas falas dos policiais, quer pelo tempo decorrido, quer pelas várias diligências de tráfico que fazem diariamente e, inclusive, no mesmo local, gerando certa confusão e não tendo condições de lembrarem dos detalhes. Inclusive, o policial José é confuso, não trouxe sua versão com início-meio-fim, narrando os fatos numa espécie de vai e vem, mais respondendo às perguntas e se recordando ao ser advertido de que sua fala em solo policial foi diversa, quando então ratificou o fato de todas não estarem com o réu e sim parte delas, o que não vislumbro como contradição séria a ponto de embasar uma absolvição, dado que drogas foram apreendidas com o acusado, o que em si é o mais importante, não se podendo exigir dos agentes públicos que se recordem de detalhes, embora o policial pudesse ter lido para se recordar da prisão desses autos. Mas o fato é que os dois policiais afirmaram sempre, que o réu, por eles

reconhecido, era quem estava na biqueira, sozinho, vendendo drogas, tanto que com ele foram apreendidas pedras de crack e dinheiro, tudo sem prova contrária, como também já visto.

Ora, a Defesa constituída do acusado não comprovou que ele teria feito um serviço de limpeza de entulho para uma senhora da favela e com esse dinheiro que ele teria adquirido o entorpecente, até porque, como visto, os policiais viram o réu, por eles reconhecido, e quem estava sozinho na biqueira, entregando algo a outrem, que por sua vez foi embora e ele permaneceu no local, o que indica ser ele o traficante, e por isso ter sido abordado.

Ainda, pouco crível que o réu tenha pago pelas drogas e ainda ter dado caixinha para o traficante, quem teria ficado escolhendo cinco das melhores e maiores pedras de crack para ele, e ainda teria lhe dado o troco de oito reais. Ora, é de conhecimento notório que no tráfico não se demora na mercancia. Não se fica escolhendo a droga, seu tamanho, aparência. Nem se dá troco. É toma lá dá cá. Jogo rápido, para não levantar suspeita nem dar tempo de algum dos envolvidos ser preso, até por estar disperso, ou melhor, entretido com outras coisas que não a chegada da polícia.

Portanto, em que pese haver apenas os relatos dos policiais civis como prova vocal a embasar a condenação, é fato que inexisteu outra testemunha que pudesse ser ouvida, nem mesmo prova favorável ao réu. Não bastasse isso, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Assim como eventual condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Ademais, em audiência de custódia, o réu alegou ser serralheiro, e ter casa própria, residência fixa (fl. 56), o que não condiz com sua versão prestada nessa audiência, de que estava em estado de drogadição, como morador de rua. Mas como já dito, o fato do réu ser usuário de droga não exclui a condição de ser também traficante, até para o sustento de seu vício.

Dito isso, afasto pedido da Defesa de desclassificação para porte de droga para consumo próprio, pois como já dito, o réu foi visualizado vendendo droga e em poder de três tipos de narcóticos diversos, e dinheiro, proveniente das vendas deles.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade e variedade de narcóticos (16 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (fl.09) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos

delitos, assim como a pouca quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (16 no total) o que não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência comprovada as fls. 23/24 (condenação por roubo pela 5ª Vara Criminal de SBC) a agravar a pena em 1/6, alcançando 05 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa, por ausente atenuantes a se considerar.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018).

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, considerando ainda, a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena superior ao máximo permitido em lei) e subjetivo (agente não é primário).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de cinco meses, e sem direito sequer à

progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JORGE LUIZ SILVA DUARTE, qualificado a fls. 16, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Oficie-se.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesp, ante a constituição de Advogado particular, sem pedido de concessão de justiça gratuita, nem juntada de declaração de hipossuficiência, nem prova dessa.

Decreto a perda de numerário apreendido (fl.09 e 48), proveniente da mercancia ilícita, conforme art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA